

1015132-61.2021.8.26.0320

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Marcelo Ielo Amaro

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 4ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... partes. RECURSO DO RÉU - Relação de consumo - Roubo do celular da autora comprovado - Realização de compras no cartão bancário e efetivado um empréstimo, além de transferências via PIX, de forma sequencial, após o evento criminoso, em dissonância com o uso regular da conta pela autora - Ausência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro - Falha na prestação dos serviços ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

4ª Vara Cível

Via Antônio Cruanes Filho S/N, Limeira - SP - cep 13480-672

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1015132-61.2021.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1015132-61.2021.8.26.0320

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Mariana da Silveira Lima

Requerido:

Banco Original S/A e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcelo Ielo Amaro

VISTOS

Trata-se de ação ajuizada por MARIANA DA SILVEIRA LIMA em face de BANCO ORIGINAL S/A e CLARO S/A. Aduz a autora que por ato ilícito imputado às rés veio a sofrer dano moral e material que ora postula sejam reparados com a procedência da ação; como fundamento sustenta falha na prestação dos serviços pelas rés, permitindo acesso de terceiro estelionatário em sua conta de telefonia móvel manipulando-a e impedindo seu acesso por período no qual o fraudador acessara, também, seu aplicativo bancário, utilizando-o para a realização de movimentações financeiras não reconhecidas pela autora. A petição inicial veio acompanhada de procuração e documentos. Citadas, as rés ofereceram contestação em peças autônomas. O Banco réu suscitou preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, negou a prática de qualquer ilícito ensejador de responsabilidade civil, imputando falha à operadora Claro S/A e, ainda, culpa exclusiva da autora que não teve zelo em proteger sua senha deixando o estelionatário acessa-la para realizar as compras impugnadas. A corré Claro S/A, suscitou preliminares de ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva. No mérito, se insurgiu contra a pretensão da autora nos

termos em que contido no pedido, imputando culpa exclusiva da autora consumidora que indevidamente salvou suas senhas bancárias no celular e, também, de terceiro estelionatário o qual através de golpe acessou os aplicativos do celular da autora, praticando ilícitos, tendo a ré efetuado a troca do chip assim que a autora reclamou acerca da clonagem de sua linha telefônica. Seguiu-se réplica. O feito foi saneado, abrindo-se a fase de instrução na qual houve colheita do depoimento pessoal da autora, bem como colheita de prova testemunha arrolada pela autora. Encerrada a instrução, conferiu-se oportunidade às partes para se manifestarem em alegações finais.

É o breve relatório.

Passo à fundamentação e decisão.

Inicialmente, insta salientar que a preliminar suscitada de ausência de interesse de agir foi devidamente apreciada e afastada por decisão saneadora, a qual restou atingida por seus efeitos preclusivos. Ainda conforme decisão saneadora, as preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas pelas rés se confunde com o mérito e com ele serão devidamente apreciadas.

No mérito, segundo se infere dos autos, imputa a autora às rés a prática de ilícito civil, consistente na indevida permissão de irregular acesso de dados do chip de sua linha telefônica móvel, sem sua autorização, a terceiro estelionatário que se passou por ela, solicitando cancelamento da linha, junto à operadora corre Claro S/A que o atendeu, procedendo a alteração sem que antes aferisse a autenticidade da cliente, circunstância que levou ao impedimento de acesso da autora à sua própria conta e dados móveis por período suficiente ao estelionatário para a prática ilícita de acesso, também, ao seu aplicativo bancário e realização de seis compras indevidas, utilizando-se para tanto de valores constantes da conta corrente da autora. Teria a autora, nos dias 22 e 23 de novembro de 2021 realizado um pagamento via PIX, outro pagamento via boleto e realizado três compras com cartão de débito no comércio local desta comarca, quando passou a notar que os serviços de dados de sua internet e linha móvel pararam de funcionar. Ainda, percebeu estar sem acesso a sua conta bancária, sendo que na manhã do dia seguinte ao tentar, mais uma vez, acessar o aplicativo do Banco réu, se valendo do wi-fi de sua residência, recebeu informação de “senha incorreta”, tendo, então solicitado a recuperação de senha e, ao conseguir e consultar o extrato bancário observou que teriam sido feitas várias movimentações financeiras de compras que não reconheceu, as quais esvaíram quase por completo os recursos que detinha em sua conta bancária e, não obstante tenha lavrado boletim de ocorrência e requerido solução ao Banco réu administrativamente, este, após análise não reconheceu qualquer irregularidade nas aludidas compras. Igualmente, tendo sido alertada pelo delegado de polícia onde lavrara o boletim de ocorrência sobre a suspeita de que a alteração de sua linha telefônica que não funcionava tenha sido usada para a prática do delito, se dirigiu ao estabelecimento da corre Claro S/A, narrando o ocorrido, obtendo informação junto a atendente da mesma de que, de fato, a linha telefônica havia sido fraudada por alguém de nome “Marco”, se recusando a dar-lhe maiores informações, apenas reativando a linha da autora, a qual passou a receber mensagens atrasadas de alerta do Banco réu acerca das compras que reputa suspeitas.

Os réus, por sua vez, se insurgiram contra a pretensão da autora, negando a falha na prestação dos serviços. O corréu Banco imputou falha à corre Claro S/A que deixara de aferir a autenticidade da cliente, antes de atender à solicitação do aludido estelionatário que teria se passado por ela, cancelamento a linha, cujo acesso retirou da autora. Assim como culpa exclusiva da autora que não cuidou de zelar pela guarda da senha, permitindo acesso ao fraudador para realizar as compras impugnadas, as quais só poderiam ser realizadas com o uso de senha, tendo, então, o ilícito ocorrido fora do âmbito das operações bancárias, se tratando de fortuito externo, não constatando o Banco nenhuma irregularidade nas compras realizadas. A corre Claro S/A imputou culpa exclusiva à autora consumidora que indevidamente salvou suas senhas bancárias no celular e, também, culpa de terceiro estelionatário

o qual através de golpe acessou os aplicativos do celular da autora, praticando ilícitos.

Diante da controvérsia instaurou-se a instância, abrindo-se a fase de instrução na qual houve colheita do depoimento pessoal da autora a qual ratificou o quanto sustentando na causa de pedir, acrescentando que tentou contato com as lojas onde as compras impugnadas foram realizadas, não obtendo sucesso algum, asseverando, ainda, que referidos estabelecimentos se encontram há mais de três mil quilômetros de distância de onde ela mora e que as compras foram realizadas em intervalos de minutos e em período em que a autora estava trabalhando, além de tais movimentações destoarem do seu perfil de uso do cartão. E, no que tange à corre Claro S/A, asseverou ter obtido informações de atendente da mesma de que uma pessoa, que não a autora, teria contatado a operadora solicitando o cancelamento da linha e internet da mesma um dia antes de do serviço de seu celular parar, ocasião em que as compras fraudulentas teriam sido realizadas, só vindo informações via aplicativo de referidas movimentações suspeitas após a reativação da conta pela Claro S/A, após a reclamação da autora. Por fim, ao ser instada, negou a autora de que tivesse salvo ou guardado de alguma maneira a senha de sua conta no aparelho celular.

A testemunha Amanda Jaqueline de Lima Nascimento, arrolada pela autora, alegou trabalhar como secretária na clínica da autora e que, no dia dos fatos, não conseguia contato com a mesma através do celular dela, vindo posteriormente esta ligar para a testemunha, mas através de outro celular de propriedade de familiar e esclarecer que seu aparelho estava sem serviço e que fora vítima de um golpe, tendo sumido valores expressivos de sua conta corrente.

Encerrada a instrução, da análise do conjunto probatório emergido dos autos, sob o crivo constitucional do contraditório, é possível distinguir falha na prestação dos serviços tanto da corre Claro S/A quanto do correu Banco Original S/A. A propósito, olvidaram-se as rés se tratar de relação de consumo a havida com a autora.

De fato como a própria corre Claro S/A veio a admitir a existência de golpe perpetrado por terceiro estelionatário que se fizera passar pela cliente autora, solicitando o cancelamento dos serviços de telefonia móvel da mesma no período em que se deram as compras impugnadas. Observa-se que referida corre procedera ao atendimento da solicitação sem se acautelar de qualquer prévia verificação acerca da autenticidade do solicitante, deixando de aferir se o mesmo se tratava realmente de sua cliente ou não, inclusive, colacionou aos autos tela de sistema dando conta de que na noite anterior às movimentações bancárias fraudulentas, teria se dado aludida solicitação a qual fora atendida pela ré. Trata-se de verdadeiro reconhecimento jurídico do pedido, ao reconhecer tal golpe e, por conseguinte, sua falha, eis que não há como se eximir de sua responsabilidade civil diante da relação de consumo caracterizada e, sobretudo, do reconhecimento de que sua preposta procedera ao atendimento de solicitação do fraudador sem qualquer checagem, não revelando a prova nenhuma situação culpa exclusiva da vítima, ora autora. Observa-se que tal circunstância que consistiu em impedimento de acesso aos dados móveis e internet pela autora dos serviços da referida corre, acabou por contribuir de forma bastante eficaz para a mesma tivesse dificuldades tomar conhecimento de que estava sendo vítima das movimentações bancárias fraudulentas, inclusive, nota-se que o atraso no recebimento das mensagens através dos serviços de telefonia alertando-a sobre as compras do estelionatário, acabou por retirar-lhe condições de ter conhecimento tempestivo e com isso controlar e tentar cancelar, impedir a consecução de referidas movimentações que se sucederam em espaço de poucos minutos.

Quanto ao correu Banco Original S/A, não obstante seus argumentos em sentido contrário, igualmente, há de lhe imputar falha na prestação dos serviços, permitindo acesso ao mesmo de terceiro estelionatário para a prática de movimentações bancárias consistentes em diversas compras em curto espaço de tempo,

com indevida utilização dos recursos constantes da conta corrente da autora e em estabelecimentos suspeitos, compra estas desatreladas do perfil de compra da consumidora, conforme se observa dos extratos colacionados aos autos por esta.

Por força da Lei 8078/90, inequívoca a legitimidade de ambas as rés para responder pelos danos suportados pela autora face a evidente falha na prestação dos serviços, onde frisa-se, emergiu evidenciado da prova que a corré Claro S/A atendeu a pedido de estelionatário impedindo acesso de dados móveis da autora à sua própria conta de celular, sem qualquer autorização desta, viabilizando que referido terceiro fraudador tivesse acesso não só à seus dados móveis como da autora, em detrimento da mesma, como, também, ao aplicativo bancário disponibilizado pelo corréu Banco Original S/A que passou a ser utilizado pelo estelionatário para realizar as compras indevidas distinguidas na causa de pedir e em desacordo com o seu perfil de consumidora, sem que referido Banco identificasse tal circunstância, possibilitando sua efetivação, como se regular fosse.

Convém destacar que, incontestável a aplicação do festejado Código de Defesa do Consumidor, pois patente a relação de consumo; como já destacado, a frágil justificativa apresentada pelas defesas demonstra, à evidência, a responsabilidade dos prestadores réus pelo fato do serviço, na qualidade de telefonia e instituição bancária. Não é por demais destacar o disposto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90, impondo às rés o ônus da prova, circunstância da qual não se desincumbiram, não trazendo aos autos nenhuma prova, sequer indícios a corroborar sua tese de culpa exclusiva da autora, a qual, de outra monta, comprovou nos autos a responsabilidade das rés.

Não se olvide, portanto, da responsabilidade civil objetiva e solidária dos fornecedores que integram a cadeia de consumo, nos termos dos artigos 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor, diante de falha na prestação dos serviços de telefonia e bancário.

Ainda, insta anotar que, não há como deixar de observar que a dinâmica contratual, com a modernidade e vasta utilização dos meios e recursos de informática, passou a sensíveis modificações nos últimos anos; em minutos, segundos, são celebrados os contratos das mais diversas naturezas e objetos, limitando-se a aceitação, muitas vezes a adesão, a mera e singela digitação de números previamente entabulados pelas partes. Evidente que a celeridade emprestada a tal dinâmica em muito contribuiu e vem contribuindo para o avanço significativo da utilização dos contratos como meio de composição e interesse. Não obstante, regras essenciais de segurança e, em especial, de proteção ao aderente se fazem e se fizeram por observância legal. Em especial, na relação de consumo, a Lei 8078/90, se mostra exemplo claro de tal preocupação em preservar a fragilidade do aderente consumidor em tão complexa e ao mesmo tempo tão singela dinâmica contratual.

Neste particular as instituições tanto bancárias como de telefonia se colocam anos luz à frente no aprimoramento e na utilização de contratações e ofertas de serviços e produtos aos clientes, com contas de telefonia vinculadas a diversos aplicativos, propiciando fácil acesso. A par do conforto proporcionado ao consumidor, inequívoca a intenção maior das instituições na utilização de tais recursos, não só para captar a clientela em tão competitivo mercado, como, em especial, para redução de custos e aumento de seus lucros. O que se percebe é que tal dinâmica vem proporcionando a contento tais objetivos financeiros, à evidência da continuidade da prestação de tais serviços e da sua ampliação, cada vez mais abrangente. Eis as circunstâncias que se mostram pertinentes a destaque nas quais se insere a lide. Não é por demais destacar, sendo fato notório, que muitas fraudes vêm sendo cometidas por terceiros se utilizando dos mais diversos meios ilícitos em tão ágil e célere prestação de serviço e produtos disponibilizados. Ao contrário do que proclamado em contestação, cabe as instituições de telefonia e bancária, uma vez que colocam à disposição do consumidor tais serviços, cuidar para que sejam os mais seguros possíveis e, também, zelar pela boa prestação de serviços por parte de seus

colaboradores. Nesse sentido, inclusive, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS TELEFONIA MÓVEL TRANSFERÊNCIA DA LINHA TELEFÔNICA PARA TERCEIRO, SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA (INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DE R\$ 2.000,00) Consumidora que busca a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais (R\$ 6.650,00) e a majoração da indenização por danos morais (para R\$ 10.000,00) Empresa ré que autorizou a transferência da linha telefônica móvel para outro chip, de posse de terceiros Terceiros que, utilizando o número de celular da autora, acessaram a plataforma "Multiplus" e resgataram as milhas aéreas Ré que não se insurge contra tais fatos, não tendo interposto qualquer recurso em face da sentença Ato ilícito comprovado Responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do caput do art. 14 do CDC Nos termos do parágrafo único do art. 7º do CDC, havendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas consumeristas Não comprovação de excludente de responsabilidade (culpa exclusiva de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC) Nexô causal comprovado Resgate indevido das milhas que não teria ocorrido, caso a operadora de telefonia não tivesse autorizado a transferência do número de celular da autora para terceiros Danos materiais comprovados (resgate das milhas), o que deverá ser objeto de liquidação, para apuração do valor das passagens aéreas obtidas Danos morais inconteste, que ultrapassam o mero aborrecimento Consumidora que se viu impedida de utilizar a linha telefônica, além de ter perdido as milhas aéreas Fixação da indenização que, no caso dos autos, comporta majoração, para R\$ 10.000,00, o que bem atende ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade Demanda julgada parcialmente procedente Sentença reformada e a em parte RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível nº 1007219-23.2019.8.26.0506, 27ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Julgamento: 2 de fevereiro de 2021. Relatora: ANGELA LOPES)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS E MATERIAIS. SIM Swap. Transferência de linha do autor para chip de terceiro, sem sua anuência. Troca que permitiu acesso indevido à conta mantida junto ao Mercado Livre e Mercado Pago. Falha na prestação dos serviços das rés que permitiu indevida transferência em dinheiro. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Alegação de fraude realizada por terceiros. Responsabilidade objetiva das rés. Inexistência de prova de que a transferência da linha telefônica tenha sido feita a pedido do autor. Legítima expectativa de segurança que foi frustrada. Dever de indenizar os prejuízos causados. Precedentes. Danos morais evidenciados. Indenização devida Quantum mantido em R\$5.000,00. Sentença mantida. Recursos desprovidos". (Apelação Cível nº 1014051-75.2019.8.26.0020, 36ª Câmara de Direito Privado, Rel. Milton Carvalho, DJ 24/11/2020, g. n.)

"Apelação Ação de indenização por danos materiais e morais Prestação de serviços Telefonia Estelionato Solicitação de transferência de dinheiro via Whatsapp Cadeia de consumo Responsabilidade objetiva Sentença mantida. De acordo com a disposição dos artigos 14 e 18, do CDC, a responsabilidade dos fornecedores que integram a cadeia de consumo é objetiva e solidária ante a fato e vício do produto ou do serviço. Ficou demonstrado que o estelionato foi praticado utilizando o aplicativo de mensagens Whatsapp, o qual por sua vez, utiliza o número de telefone vinculado ao chip/aparelho. Dessa forma, se o consumo é iniciado com a contratação de uma linha telefônica para, depois, ocorrer o uso do aplicativo e a troca de mensagens, a requerida, na condição de operadora telefônica, faz parte da cadeia de consumo e deve ser responsabilizada por eventuais danos decorrentes destes serviços. Nada impede que eventual prejuízo cometido por terceiro possa ser arguido pela via adequada. Apelação desprovida, com observação". (Apelação Cível nº 1005239-33.2020.8.26.0562, 30ª Câmara de Direito Privado, Rel. Lino Machado, DJ 02/12/2020)

AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA - Sentença de parcial procedência - Recursos de ambas as partes. RECURSO DO RÉU - Relação de consumo - Roubo do celular da autora

comprovado - Realização de compras no cartão bancário e efetivado um empréstimo, além de transferências via PIX, de forma sequencial, após o evento criminoso, em dissonância com o uso regular da conta pela autora - Ausência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro - Falha na prestação dos serviços evidenciada - Responsabilidade objetiva da instituição financeira - Fortuito interno - Súmula nº 479 do STJ - Dever de indenizar pelos danos materiais - Precedentes - Recurso não provido. (...). Recurso do réu não provido e recurso da autora provido, com determinação. (Apelação Cível nº 1116207-27.2021.8.26.0100, 15ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Julgamento: 6 de outubro de 2022. Relator: ACHILE ALESINA)

Frisa-se, não há qualquer caracterização de culpa exclusiva da autora. Como já ressaltado, as circunstâncias trazidas aos autos refletem a falha do serviço e a culpa necessária à reparação do dano. Por conseguinte, inquestionável que a autora foi vítima de ato ilícito cujo dano decorrente há de ser ressarcido.

Nesse particular, pretendeu a autora indenização a título de danos morais e materiais.

Quanto aos danos materiais pugnou fossem as rés condenadas, solidariamente, a ressarcirem os valores indevidamente utilizados de sua conta corrente nas compras fraudulentas assim descritas na causa de pedir, equivalente a R\$ 8.598,75, o qual, apesar de impugnado pelas rés, não lograram estas desconstituí-lo. Nesse particular, considerando os termos da presente fundamentação onde se reconhece a falha na prestação dos serviços por parte de ambas as rés, o que possibilitou a aplicação do golpe, retirando da autora qualquer condição de evitar ou controlar o ilícito durante sua prática, consistente nas aludidas movimentações indevidas, há de se impor a reparação do dano material experimentado pela autora, razão pela qual deverá ser adotado referido valor para recomposição do dano. O valor deverá ser devidamente corrigido desde o desembolso, aplicando-se juros de mora desde a citação.

Por fim, sobre o dano moral que alega a autora ter suportado, não há como reconhecer a indenizabilidade. De fato, a inércia das rés no atendimento à solicitação da autora não passa de mero aborrecimento, não refletindo efeitos para a proclamação de responsabilidade civil à reparação de tal lesão imaterial.

Também neste sentido o Egrégio Tribunal de Justiça vem entendendo predominantemente, ressalvado circunstância excepcional que coloque o conveniado ou contratante em situação de extraordinária angústia ou humilhação, no caso inexistente na espécie; não se vislumbra dano moral, lesão imaterial passível de ser indenizada; trata-se, em verdade, de mero aborrecimento que muitas vezes se submetem os consumidores nas incontáveis relações consumeristas que se dão no cotidiano. As circunstâncias narradas não são capazes de produzir qualquer repercussão que pudesse ultrapassar os lindes da mera contrariedade, do mero aborrecimento, algo absolutamente incapaz de permitir o reconhecimento de mal maior que pudesse macular o espírito humano, mesmo daquele mais sensível.

Nessa conformidade, se traz à baila judicioso julgado da lavra da Eminente Desembargadora Angela Lopes, segundo o qual:

No mais, indiscutível que nem todo desconforto, nem toda dor, nem todo mal-estar configura dano moral, fazendo-se necessário que a ofensa gere consequência imbuída de importância e gravidade significantes, sob pena de banalização do instituto, não tendo sido descrito sofrimento algum que permita concluir pela ocorrência do indigitado prejuízo (Apelação Cível nº 1021240-52.2019.8.26.0005; 27ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo)

Posto isso e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação ajuizada por MARIANA DA SILVEIRA LIMA em face de BANCO ORIGINAL S/A e CLARO S/A,

para condenar as rés a indenizarem, solidariamente, a autora, no importe de R\$ 8.598,75, a título de dano material. O valor deverá ser devidamente corrigido desde o desembolso, aplicando-se juros de mora desde a citação. Reciprocamente vencidas, deverão as partes arcar com a honorária da parte adversa que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, rateando as custas do processo, respeitadas a isenções e suspensão decorrentes da gratuidade concedida à autora (artigo 98, parágrafos 2º, 3º e 4º do Código de Processo Civil).

Publique-se e intímem-se as partes.

Limeira, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA